

1502827-92.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... que estava no local para praticar tráfico, por estar passando por necessidades. Quando saiu correndo, o fez em direção a um escadão.

No mesmo sentido, a testemunha Robson Rosa da Silva, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina por localidade conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, quando avistou o acusado, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n.º 01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502827-92.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1502827-92.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312303/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21425761 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3672/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2312303 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDER FERNANDO DOS SANTOS ESTEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Wender Fernando dos Santos Esteves, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 18h50min, na Rua Poá, 150, Jd. Santa Filomena, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu guardava e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: a) 77 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 215g de massa bruta; b) 151 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 172g de massa bruta e c) 87 pedras de crack, pesando, aproximadamente 55g de massa bruta; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 25,50 (vinte e cinco reais) em espécie, fruto do tráfico de drogas. Laudo prévio de constatação da droga às fls. 16/21.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 39/41.

A denúncia foi recebida à fl. 51, em 14 de dezembro de 2021.

Certidão de antecedentes criminais do Réu à fl. 60.

Regularmente citado (fl. 77), o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 101/102. Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Luciana Mendes da Rocha e Anderson Ferreira de Oliveira, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 124/130 e 134/171.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No que se refere à alegação de nulidade suscitada pela Defesa, essa se confunde com o mérito, sendo com este analisado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

03/05, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 06, e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 16/21 e fls. 39/41, respectivamente.

A autoria do delito, por sua vez, é incontroversa, estando comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Willian da Silva Dias, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina por local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando avistou o Réu, o qual, tão logo percebeu a presença dos agentes públicos, tentou se evadir correndo. Por esse motivo, o declarante e seu companheiro de equipe saíram em seu encalço. Em revista pessoal, lograram êxito em encontrar drogas em sua posse, bem como dinheiro. Ele não chegou a jogar a sacola e ficou com ela em mãos o tempo todo. No interior da referida sacola, havia cocaína, crack e maconha. O acusado relatou que estava no local para praticar tráfico, por estar passando por necessidades. Quando saiu correndo, o fez em direção a um escadão.

No mesmo sentido, a testemunha Robson Rosa da Silva, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina por localidade conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, quando avistou o acusado, que imediatamente saiu correndo. O declarante viu que ele estavam com algo em mãos. Por tais motivos, saiu em seu encalço junto com seu companheiro de equipe, que foi quem fez a abordagem. Ao alcançá-lo, verificaram a presença de substâncias entorpecentes no interior da sacola que estava em suas mãos, bem como de quantia em dinheiro. O Réu alegou que estava passando por dificuldades financeiras, por isso, estaria na venda de entorpecentes.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional. Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento dos guardas municipais só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista esse se encontrava em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, na posse de sacola plástica, e, ao avistar os agentes públicos, tentou imediatamente empreender fuga -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Por outro lado, em interrogatório, o Réu apresentou versão incapaz de infirmar o panorama fático probatório desfavorável.

Em juízo, o acusado aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, saiu de sua casa por volta de 18h para comprar drogas, quando viu o "vapor" correndo. Saiu também em fuga pelo escadão com medo da polícia. O "vapor" largou a sacola e os agentes públicos disseram que ela pertencia ao declarante, por não terem encontrado o verdadeiro responsável. Já foi enquadrado por esses guardas municipais em ocasião anterior. Não deu tempo de comprar as drogas. Os R\$ 25,00 encontrados eram do declarante e se destinavam a comprar drogas. Não conhece o "vapor" da biqueira nem o "olheiro". Estava escuro no dia dos fatos. Foi preso em março de 2022 por tráfico em outro local.

Nota-se que a versão apresentada pelo Réu é fantasiosa e não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso da instrução, bem como na realidade fática. Isto, pois não é crível que os agentes públicos o teriam imputado a posse de entorpecentes à revelia da lei e sem qualquer motivo aparente.

Ademais, ambos os guardas municipais foram uníssomos em apontar que o acusado assumiu a prática delitiva no momento da prisão, em razão de estar passando por dificuldades financeiras, além de a sacola com entorpecentes estar em suas mãos (e não apenas próxima a ele), inexistindo em seus relatos quaisquer contradições que permitam inferir flagrante forjado.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público (via pública), em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

“Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que se refere à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto parte se encontrava pulverizada em pequenas porções (consoante auto de exibição de fl. 06, em mais de trezentas unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros.

Deste modo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, inexistem provas nos autos que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade de droga (441,63g brutos – fls. 17/18) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço como pena-base 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide ao caso a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP). Conquanto o acusado tenha negado a prática delitiva em juízo, foi utilizada para a fundamentação desta sentença a confissão informal narrada pelos guardas municipais – inteligência da Súmula nº 545, STJ. No entanto, por se encontrar a pena em seu mínimo legal, deixo de efetuar a redução da pena, nos termos da Súmula nº 231, STJ. Em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente e a existência de bons antecedentes ao tempo do crime (certidão de fl. 60), bem como a ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Apesar de o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispor que a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena – sendo possível a compreensão de que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos –, entendo ser necessário que haja, ao menos, sentença condenatória proferida em outro processo ou a verificação de situações evidentes, tais quais diversas prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo, de modo a impedir a incidência da minorante em questão.

Como nos autos do processo nº 1500875-44.2022.8.26.0544 não houve condenação do Réu nem em primeira instância e não há provas nos autos que comprovem prisões reiteradas anteriormente aos fatos em questão, não é possível aferir, com algum

grau de certeza, que este, de fato, se dedica à prática de atividades ilícitas. Em outras palavras, inexistindo sequer condenação em primeiro grau de jurisdição, a presunção de não culpabilidade do acusado permanece hígida, não sendo mitigada pela simples existência de inquérito ou processo judicial em curso. Ademais, caso seja afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 em razão da existência de ação penal em curso e o Réu venha a ser nessa inocentado ulteriormente, a fundamentação desta sentença terá se baseado em fato não reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, o que importaria em contradição na prestação jurisdicional.

Logo, ante a ausência de ao menos sentença condenatória em tal processo – com vistas a mitigar a presunção de inocência do Réu quanto ao envolvimento em atividade reiterada de tráfico –, inviável acolher o pedido de afastamento de causa minorante da pena nesta decisão, com base na existência de ação penal em curso, cuja instrução sequer se encontra finalizada.

Ademais, o fato investigado nos autos do processo nº 1500875-44.2022.8.26.0544 ocorreu em data posterior ao apurado nos presentes autos, o que inviabiliza a sua consideração para verificar Maus antecedentes e/ou personalidade do Réu ao tempo do crime sob exame, não podendo ser utilizado, igualmente, para concluir se o acusado já se encontrava praticando, em 16 de outubro de 2020, tráfico de forma reiterada. Sendo assim, reduzo a pena em 1/3, em razão da pequena quantidade de entorpecentes e circunstâncias da prisão. Deixo de efetuar a redução em seu máximo, ante a excessiva pulverização da droga, em mais de trezentos invólucros.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado ao condenado cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Wender Fernando dos Santos Esteves como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, mediante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes acima fixados.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), praticando o delito de tráfico, determino o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06, porquanto inexistentes nos autos provas que permitam inferir que tal quantia não se originou das vendas realizadas no âmbito do crime em questão.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum

de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto, e a substituição por restritivas de direito. Expeça-se alvará de soltura clausulado neste feito. Anoto que consta dos autos que o acusado também se encontra preso em razão do processo nº 1500875-44.2022.8.26.0544.

Expeça-se guia de recolhimento provisório, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA